

1510287-59.2019.8.26.0655

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Érica Midori Sanada

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

1ª Vara

Avenida Fernão Dias Paes Leme, 2323 / 2329, Varzea Paulista - SP - cep 13220-005

1510287-59.2019.8.26.0655 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1510287-59.2019.8.26.0655

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Victor Felipe Silva Rebecchi

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Midori Sanada

Vistos.

VICTOR FELIPE SILVA REBECCHI, já devidamente qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 171, § 4º do Código Penal, porque no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 18h00min, na Avenida Fernão Dias Paes Leme, nº 2827, Núcleo Residencial Sequoia, nesta cidade e Comarca de Várzea Paulista, agindo em concurso e unidade de propósitos com mais dois indivíduos ainda não identificados, teria obtido, para si, vantagem indevida no valor de R\$ 12.159,66 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em prejuízo da vítima Elena Xavier, idosa com 77 anos à época dos fatos, induzindo-a em erro, mediante meio ardil.

A denúncia foi recebida em 20 de agosto de 2021 (pág. 167/168).

O réu foi pessoalmente citado (pág. 173/174) e apresentou defesa (pág. 180/182).

Na resposta à acusação, a Defesa salientou que irá se manifestar sobre o mérito

após a instrução processual, oportunidade em que restará demonstrada a inocência do réu.

Em audiência de instrução, foi ouvida a testemunha arrolada, sendo, por fim, o réu sido interrogado.

Em debates orais finais, pugnou o(a) representante do Ministério Público pela procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Em seguida a Defesa pugnou pela improcedência da ação, alegando fragilidade probatória.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDIDO.

Da Materialidade:

A materialidade do crime ficou comprovada pela portaria (pág. 02/03), pelo boletim de ocorrência (pág. 04/05 e 06/07), pelo auto de reconhecimento fotográfico POSITIVO (pág. 1013), pelo auto de avaliação indireto (pág. 37), pelo reconhecimento pessoal em juízo, bem como pelo depoimento colhido na fase policial e confirmado em juízo.

Do Conjunto Probatório:

Na fase policial, o réu VICTOR FELIPE SILVA REBECCHI, informou que:

“Deseja permanecer calado e se manifestar apenas em juízo”. Em juízo, informou que era apenas motoboy contratado para retirar objetos. Que não sabia qual era o conteúdo do envelope. Que não era de Várzea Paulista e sim de São Paulo. Que era contratado por meio de Whatsapp. Que era contratado apenas para ir até o local e retirar envelopes. Que recebia pelo serviço prestado em espécie. Que não se recorda dos nomes das pessoas que lhe contratavam para tais serviços. .

Por fim, a vítima ELENA XAVIER, assim relatou na fase policial:

“Que no dia 08 de agosto de 2019, por volta das 17h45min, recebeu uma ligação em seu telefone fixo onde um homem se apresentava com o nome de Felipe, que disse ser representante da Febraban, o qual informou que o seu cartão bancário havia sido clonado, tendo que, portanto, ir urgente até São Paulo para fazer um novo cartão. Que a vítima lhe respondeu que seria impossível ir até São Paulo, sendo que Felipe disse que iria passar o atendimento para outro funcionário da Febraban, de nome Ricardo Rodrigues de Oliveira, que passou a atendê-la e lhe disse que iria cancelar o seu cartão, pois foi clonado e estava sendo usado para fazer compras e outras transações por pessoas desconhecidas, e que outro cartão lhe seria enviado num prazo de três dias. Que o atendente Ricardo lhe pediu por telefone a senha dos cartões e afirmou que um motoboy iria até a sua residência para buscar os cartões. Que a vítima então por telefone, forneceu a Ricardo, as senhas dos cartões dos bancos CEF, Banco Itaú e Bradesco. Que Ricardo lhe informou que se não informasse a senha para ele, os clonadores iriam fazer on-line as transferências dos outros cartões. Que já passava das 18h30min, quando na frente de sua casa apareceu um motoboy que descreve como sendo de pele morena, jovem, aparentando uns 25 anos de idade e mais ou menos 1,70 de altura, que apertou a campainha e ficou próximo a motocicleta e tinha na cabeça um capacete que estava erguido até a altura da testa, mostrando o seu rosto. Que nesta especializada, os policiais lhe exibiram algumas fotográficas e, entre elas, reconheceu o motoboy que foi até sua casa pegar os seus cartões que foram colocados num envelope que lhe foram entregues. Que na conta poupança da CEF experimentou um prejuízo de aproximadamente R\$ 8.500,00. Que do Banco Itaú, conta poupança, experimentou um prejuízo de aproximadamente R\$ 2.500,00. Que do Banco Bradesco experimentou um prejuízo de aproximadamente R\$ 2.360,00”. O que foi ratificado em juízo. Que foram levados três cartões da

depoente. Que possui 79 anos de idade. Que não reconheceu nenhuma das pessoas apresentadas na presente audiência, como sendo o réu. Que reconheceu o réu junto a delegacia. Que reconhece a pessoa apresentada as fls. 13, como sendo o réu.

Do Depoimento da Vítima:

Não há razões para que os depoimentos prestados pela vítima sejam acolhidos com reserva, já que "em delitos como o da espécie, prevalecendo, sem qualquer razão para retificação dos autores, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACrim - Ap. nº. 440.643-6 - 8ª Câmara - j. 23.7.86 - Rel. Juiz Canguçi de Almeida, v.u., JUTACrim 91/407).

É inegável, consoante a jurisprudência majoritária, que a palavra da vítima, em sede de delitos patrimoniais, é extremamente relevante, pois, a princípio, não tem ela qualquer motivo para incriminar quem quer que seja.

Nesse sentido, importante colacionar os seguintes julgados:

"A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer a do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais elementos de convicção existentes nos autos" (TACRIM-SP-AC Rel. Celso Limongi JUTACRIM 94/341).

"Constitui prova suficiente para condenação em crime de roubo o fato da vítima reconhecer o agente com firmeza e determinação, uma vez que não tem motivo algum para incriminar um desconhecido falsamente" (TACRIM-SP-AC- Rel. Passos de Freitas RJD 22/309).

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores" (Rel. ALMEIDA BRAGA JUTACRIM 100/250).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e das declarações da vítima.

Do Crime de Estelionato:

O réu foi denunciado, porque agindo em concurso e unidade de propósitos com mais dois indivíduos ainda não identificados, teria obtido, para si, vantagem indevida no valor de R\$ 12.159,66 (doze mil, cento e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos), em prejuízo da vítima Elena Xavier, idosa com 77 anos à época dos fatos, induzindo-a em erro, mediante meio ardil.

Vale aqui salientar, que a Lei n.º 13.964/2019, inseriu o § 5º, no artigo 171, do Código Penal, disciplinando que referido delito somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for maior de 70 anos de idade, o que é o caso dos autos, eis que nascida em 19/06/1942, portanto, contava com 77 anos de idade, à época dos fatos (pág. 24/25). Diante desse novo cenário, desnecessária a representação da vítima.

No que tange ao delito, o artigo 171, § 4º, do Código Penal, assim disciplina:

"Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis".

"§ 4º - A pena aumenta-se de 1/3, ao dobro, se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso".

Ao invés da clandestinidade, da violência física ou da grave ameaça, o agente, no estelionato, emprega o engano, a astúcia, o engodo, sem alarde ou estrépito.

O estelionato é o crime patrimonial mediante fraude, é a forma evoluída de captação do alheio.

Para configuração do estelionato, portanto, o agente, num primeiro momento (de início), deve empregar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.

Artifício pode ser definido como uma certa encenação material, com a utilização de algum aparato ou objeto para enganar a vítima, isto é, o agente com determinado "mise en scène" ou estratagema provoca ou mantém em erro a vítima.

Ardil é a conversa enganosa; já não se trata da fraude material, mas a intelectual. Entretanto, a diferença entre artifício e ardil, em face de nossa legislação, é de valor relativo, já que, logo após mencioná-los, o legislador empregou a fórmula genérica ou qualquer outro meio fraudulento; isto é, nessa fórmula estão, sem dúvida alguma, incluídos o artifício e o ardil.

De outra parte, o meio iludente empregado pelo agente deve ser idôneo, isto é, apto a enganar a vítima; se, desde o início, o meio já se mostrava absolutamente ineficaz para iludir o sujeito passivo, é o caso de crime impossível, não caracterizando, assim, o estelionato.

"Se desde o início da 'mise-en-scène' a vítima percebeu que se tratava de uma malandragem do acusado, à evidência de ter ocorrido na espécie inidoneidade absoluta do meio empregado, a desnaturar a figura do estelionato, configurando delito impossível" (TACRIM-SP - AC - Rel. Toledo de Assumpção - RT 418/262).

Para caracterização do estelionato, a doutrina, de forma quase majoritária, entende necessário o dolo genérico, isto é, a vontade consciente do agente de empregar o meio fraudulento para iludir alguém, e o dolo específico, que a intenção de tornar-se dono da coisa.

O dolo deve, também, ser anterior (antecedente, preordenado) ao uso da fraude e à obtenção da vantagem ilícita, pelo erro da vítima (se posterior, há crime de apropriação indébita).

"O dolo necessariamente antecede à obtenção da vantagem indevida, de tal modo que, se, em dado caso, o dolo só incidiu depois daquela obtenção, é juridicamente impossível cogitar-se do delito" (TACRIM-SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - RT 692/287). Ainda nesse sentido: RT 434/370, 430/366, 419/290.

O estelionato é um crime material, e assim, a consumação se dá quando ocorre a produção do resultado, ou seja, o crime se consuma no momento em que o agente consegue obter a vantagem ilícita, em prejuízo da vítima.

"No estelionato típico, o crime consuma-se no momento em que a vítima é desfalcada em seu patrimônio e o agente obtém a vantagem indevida" (TACRIM-SP - Ver. - Rel. Hélio de Freitas - JUTACRIM 87/24).

"O estelionato é crime material de dano, tendo o seu momento consumativo quando obtém o agente indevida vantagem patrimonial após ilaquear a boa-fé da vítima" (TACRIM-SP - HC 131.038 - Rel. Renato Mascarenhas).

No caso em tela, é certo que o delito de estelionato atingiu sua consumação.

Em seu depoimento, a vítima esclareceu que estava em sua residência, quando no dia

08 de agosto de 2019, por volta das 17h45min, recebeu a ligação em seu telefone fixo, da pessoa se passando por funcionário da FEBRABAN, dizendo que seus cartões bancários haviam sido clonados. Foi então orientada a passar as senhas, bem como entregar os cartões ao motoboy, o que aconteceu no mesmo dia. Posteriormente, tomou ciência de que havia sido vítima do GOLPE DO MOTOBOY.

Ela então esteve na Delegacia de Polícia, e olhando o acervo fotográfico, após passar as características físicas do indivíduo, reconheceu sem sombra de dúvidas o réu, como sendo o MOTOBOY que esteve em sua residência para retirar os cartões bancários (pág. 10/13).

Em juízo, a vítima confirmou que na fase policial foi mostrada a fotografia de pag. 13, tendo procedido o reconhecimento.

O auto de avaliação de pag. 37 demonstra que a vítima teve um prejuízo líquido de R\$ 12.159,66, tendo em vista que pequena parte do valor levado pelos meliantes, foram devolvidos pelos bancos, conforme auto de avaliação (pág. 37) e extratos bancários (pág. 38/51).

Na fase policial, o réu permaneceu calado. Em Juízo, o réu confirma que foi quem buscou os cartões, mas, não sabia o que continha na entrega feita pela vítima. Também não soube declinar o nome da pessoa que lhe pagou e recebeu os cartões.

Restou evidente, que o réu juntamente com outros indivíduos não identificados, ludibriaram a vítima, para fins de obter os cartões bancários, os quais logo na sequência foram utilizados para fins de transações, restando um prejuízo considerável para a vítima.

Está igualmente prevista a causa de aumento de pena, prevista no § 4º, do artigo 171, do Código Penal, tendo em vista que o delito foi praticado contra pessoa idosa, tendo em vista que a autora nasceu em 19/06/1942, portanto, contava com 77 anos de idade, à época dos fatos (pág. 24/25), e sua vulnerabilidade foi utilizada pelos meliantes, para a prática e sucesso do estelionato.

Diante do exposto, restou comprovada a materialidade do crime de estelionato, bem como a autoria do réu.

Passo à dosimetria da pena:

Sopesados os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é REINCENTE, fato que será considerado na segunda fase de aplicação da pena. Entretanto é de se observar, que ele se aliou a outros meliantes, para praticar o delito conhecido como "GOLPE DO MOTOBOY", demonstrando que estava envolvido com uma organização criminosa articulada, o que caracteriza sua maior periculosidade, razão pela qual aplico a pena acima do mínimo legal em 1/6, resultando em: 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, observo a agravante da REINCENTE, tendo em vista que o réu já foi condenado pelo delito de roubo, com trânsito em julgado para a defesa em 15/09/2016, que tramitou perante a 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda - São Paulo, sob o número 0070502-86.2015.8.26.0050 (pág. 212/214), razão pela qual, majoro a pena em mais 1/6, resultando em: 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase de aplicação da pena, observo a causa de aumento de pena prevista no § 4º, do artigo 171 do Código Penal, tendo em vista que o delito foi praticado contra pessoa idosa, tendo em vista que a autora nasceu em 19/06/1942, portanto, contava com 77 anos de idade, à época dos fatos (pág. 24/25), e sua vulnerabilidade foi utilizada pelos meliantes, para a prática e sucesso do estelionato, razão pela

qual aumento a pena em 1/3, resultando em: 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ausentes outras agravantes ou atenuantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, esta se torna definitiva.

Do regime inicial de cumprimento da pena:

Considerando que face as circunstâncias do delito e pelo fato do réu ser REINCENTE, com condenação anterior por roubo (pág. 212/214), demonstrando sua destinação para a criminalidade, nos termos artigo 33, § 3º, do Código Penal, iniciará o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO.

Anoto que o entendimento sumular do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a fixação do regime inicial semiaberto para reincidentes cuja pena privativa de liberdade não seja superior a 04 (quatro) anos.

Súmula nº 269: "É admissível a adoção de regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

E mais: "O regime inicial aberto não é hábil a apenação de agente reincidente, de acordo com o artigo 33, "c", do Código Penal, sendo possível se a reprimenda não for superior a 8 anos, a concessão de regime semiaberto". (RJDTCRIM 31/268).

Nessa linha, ainda:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 2º, C, DO CP. REGIME INICIAL SEMI-ABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgRg no AREsp 295009 MG 2013/0052517-7. Relator: Des. Maria Thereza de Assis Moura. julgado: 06/08/2013).

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a concessão da suspensão condicional da pena - Sursis, conforme dispõe o artigo 44, inciso II e artigo 77, inciso I, ambos do Código Penal, respectivamente.

Da pena pecuniária:

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Não há que se falar na não aplicação da pena de multa, sob a alegação de que o réu é beneficiário da justiça gratuita, eis que a pena de multa está prevista no preceito secundário do tipo penal e fora estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda corporal e ainda no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício.

Nesse sentido:

Ementa: Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante - Apreensão de quantidade razoável de crack - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos - Responsabilidade do acusado comprovada - Condenação mantida; Tráfico de entorpecentes - Plena indicação de que o réu se dedica a atividades ilícitas e está ligado a organização criminosa - Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inaplicabilidade - Multa - Pena prevista no preceito secundário do tipo de tráfico de entorpecentes e estabelecida de acordo com a dosimetria da reprimenda

corporal e no mínimo legal, afigurando-se legítima e sem qualquer vício - Recurso improvido (Apelação Criminal n.º 0001590-39.2017.8.26.0544 - da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -Relator: Alexandre Almeida - Julgamento: 08/04/2021).

Do Dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação que o Ministério Público move em face de VICTOR FELIPE SILVA REBECCHI, já devidamente qualificado nos autos, para o fim de CONDENÁ-LO como incurso nas penas do artigo 171, § 4º, do Código Penal à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicialmente no SEMIABERTO, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal.

Face o entendimento dos Tribunais Superiores, o réu poderá recorrer da presente em liberdade.

Dos Efeitos da Condenação:

Custas ex lege.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arbitro em favor d(a)o(s) advogado(a) conveniado(a)(s) honorários na forma do convênio vigente. Oportunamente expeça a(s) certidão(ões).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Várzea Paulista, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA

Certifico que, na data inserida no sistema informatizado, foi publicada em cartório a r. Sentença. O escr.